

1500274-31.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2098111/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11040767 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 877/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2098111 - DEL.POL.SALTO, 877/20/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500274-31.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500274-31.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2098111/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11040767 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 877/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2098111 - DEL.POL.SALTO, 877/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL EDJAIR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu RAFAEL EDJAIR DA SILVA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 20 de abril de 2020, por volta das 15h54min, na Rua Vaticano, nº 416, Jardim União, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado vendia, bem como trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 15 (quinze) microtubos de "cocaína", com peso líquido aproximado de 7,48 (sete gramas e quarenta e oito centigramas); e b) 29 (vinte e nove) porções de "cocaína", com peso líquido de 3,92 (três gramas e noventa e dois centigramas),

tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida (fls. 40). A denúncia foi oferecida em 28 de abril de 2020 (fls.61-65 ). O réu foi notificado por edital pois mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, sendo decretada sua prisão preventiva (fls. 142). A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fl.168-169). Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 09), auto de constatação preliminar (fls. 11) e laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a presença da substância cocaína em todas as porções (fls. 74-78), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Thiago Martins e Antônio Alessandro Frois, testemunhas de acusação, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento pela Rua Vaticano, local conhecido pela venda ilícita de drogas, quando visualizaram Rafael Edjair da Silva pegando um objeto na caçamba de entulho e, em seguida, entregando para Lucas. Realizada abordagem, com Lucas foi encontrado 1 pino de cocaína e R\$ 32,00 (trinta e dois) reais e, com Rafael, a quantia de R\$ 30,00 (trinta) reais. Indagados, Lucas afirmou que foi até o local adquirir drogas e compro a droga do réu. Rafael permaneceu em silêncio. Encontraram na caçamba de entulho 15 pinos de cocaína, inclusive idênticas a encontrada em poder de Lucas, e também 29 porções de crack.

O réu, interrogado, disse que é usuário de drogas. Estava no local para comprar entorpecentes. Não praticou o tráfico.

É possível considerar os elementos de prova produzidos na fase inquisitiva, conforme art. 155 do Código de Processo Penal. Lucas Oliveira Santos, na fase inquisitiva declarou (fls. 12) que: "é usuário de drogas, e nesta data estava pelo local dos fatos, e entrou em contato com uma pessoa para comprar um "pino" de cocaína, pagando R\$ 10,00 reais. Desconhece seu nome. No momento em que comprou, a Guarda Municipal passou pelo local. Declara que então se afastou, sem ao menos receber o troco que tinha direito, e logo em seguida foi abordado pela Guarda Municipal."

A versão apresentada por Lucas na fase inquisitiva foi corroborada pelo depoimento que as testemunhas prestaram em Juízo, os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente, dizendo que viram o réu pegar droga na caçamba de entulho, entregar a Lucas e que o restante da drogas estava na caçamba, embalado e pronto para comercialização.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilícitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada

de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)".

"TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)".

O simples fato de o réu alegar ser usuário e possuir outra fonte de renda lícita não o impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum. Convém ressaltar a cautela habitual desenvolvida pelos traficantes justamente com o propósito de serem confundidos com usuários. Desse modo, é incomum tais agentes serem abordados com grande quantidade de entorpecente, pois na maioria das vezes armazenam a maior parte da droga em outro local, o que não deve ser interpretado em seu favor, mormente diante da existência de elementos probatórios corroborando um cenário de traficância.

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável.

Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, apesar da diversidade de entorpecentes a quantidade apreendida é pouco expressiva: 24g (vinte e quatro gramas) de cocaína e 5 g (cinco gramas) de crack, o réu é primário e não integra organização criminosa, tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico - Suficiência de provas - Manutenção da condenação. Penas - Aumento das básicas por diversidade e natureza dos entorpecentes - Exclusão - Quantidade pouco expressiva - Espécie de um dos tóxicos, por si só, não autoriza exasperação - Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06. Penas - Fixação no piso - Inviável maior diminuição por atenuante - Súmula 231 do STJ. Art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Necessidade de demonstração de interesse em propagar o uso de tóxicos entre aqueles que circulam pelos lugares enumerados - Não incidência. Redutor - Cabimento - Réu primário, menor, confesso e sem antecedentes - Redutor máximo - Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-63.2019.8.26.0628; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes e agravantes.

Não há outras circunstâncias a serem avaliadas na aplicação da pena.

Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL EDJAIR DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Expeça-se alvará de soltura.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA